



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 40º D.P. VILA STA MARIA

Folha :1

Boletim No.: 147/2016

INICIADO:19/01/2016 10:19hs e EMITIDO:19/01/2016 19:58hs

JMLNROCBDJEEFH\`

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: AVENIDA JOAO DOS SANTOS ABREU, 1600 - CACHOEIRINHA

CEP: 02566-020 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 40 D.P. - VILA STA MARIA

Ocorrência: 19/01/2016 às 07:20 horas

Comunicação: 19/01/2016 às 10:17 horas

Elaboração: 19/01/2016 às 10:19 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- **MARCOS VINICIUS SOUZA ALEXANDRE** - Presente ao plantão - RG: 50496551-SP emitido em 30/10/2014 - Exibiu o RG original: Não
- Pai: ANTONIO CARLOS ALEXANDRE - Mãe: ROSANGELA MONTEIRO DE SOUZA AQUINO
- Natural de: S.PAULO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 21/10/1996 19 anos - Estado civil: Solteiro
- Instrução: 2 Grau completo - CPF: 38951808823
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Preta
- Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Carapinha
- Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: CURTO
- Altura: 1,68 - Complexão: MAGRO - Observações: BRAÇO DIREITO ROSANGELA
- Endereço Residencial: RUA DR. ALMEIDA NOBRE, 215 - CSA VERDE ALTA
- S.PAULO - SP

Testemunha:

- ALESSANDRO SANTOS FRANCISCO - Presente ao plantão - RG: 30032215-SP emitido em 03/06/1993 - Exibiu o RG original: Sim
- Outros documentos: RE Nº 132.814-0 - Pai: ANTONIO FRANCISCO FILHO
- Mãe: DARCI MARIA DOS SANTOS FRANCISCO - Natural de: S.PAULO - SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 30/09/1979
- 36 anos - Estado civil: Convivente - Profissão: POLICIAL MILITAR
- Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
- Endereço Residencial: AVENIDA GASPAR VAZ DA CUNHA, 113 - LIMÃO - S.PAULO

40º D.P. VILA STA MARIA

Endereço da delegacia : AV DEP. EMILIO CARLOS, 1251 - VILA SANTA MARIA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3936-4929



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 12

Dependência: 40º D.P. VILA STA MARIA

Boletim No.: 147/2016

INICIADO:19/01/2016 10:19hs e EMITIDO:19/01/2016 19:58hs

JMLNROCBDJEEFH\`

Folha :2

SP - Telefones: (11)3936-1065 (Residencial)

Condutor:

- FABRICIO AMARO DE SOUZA - Presente ao plantão - RG: 40342601-SP emitido em 19/07/2013 - Exibiu o RG original: Sim
- Outros documentos: RE. 122.180-9 - Pai: EDGAR DE SOUZA
- Mãe: TANIA REGINA AMARO DE SOUZA - Natural de: ARACATUBA -SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 09/02/1987
- 28 anos - Profissão: POLICIAL MILITAR - Advogado Presente no Plantão: Não
- Cutis: Parda - Endereço Comercial: AV GASPAR VAZ DA CUNHA, 113
- VL SANTA MARIA - S.PAULO - SP - Empresa: 2ª CIA DO 9º BPM/M - Telefones: (11)3936-1065 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Artigos para viagem - Subtipo: Bolsa - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
- Marca: BOLSA ROSA - Pessoa relacionada: MARCOS VINICIUS SOUZA ALEXANDRE

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 1380
- Acondicionamento: TROUXINHA DE PAPEL - Quantidade: 12
- Involucro: PLÁSTICO
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 1700
- Acondicionamento: SUPOSITORIO - Quantidade: 17 - Involucro: OUTROS
- Observações: PINOS DE COCAINA

Histórico:

INFORMAM OS POLICIAIS, QUE ATENDENDO A UMA DENÚNCIA ANÔNIMA Nº W160100635-, SOBRE TRAFICO DE ENTORPECENTES, COMPARECERAM NO DIA, LOCAL E HORA DOS FATOS, ENCONTRANDO O INDICIADO EM ATITUDE SUSPEITA, QUANDO O ABORDARAM E O REVISTARAM, SENDO ENCONTRADO NO BOLSO DE SUA BLUSA UM PEQUENO ESTOJO COR DE ROSA, CONTENDO 17 PINOS DE COCAÍNA, E 12 ENVÓLUCROS DE MACONHA,; EM SEGUIDA OS TAIS POLICIAIS DERAM VOZ DE PRISÃO AO INFRATOR, APRESENTANDO A OCORRÊNCIA NESTA DELEGACIA, ONDE A AUTORIDADE POLICIAL, DETERMINOU A APREENSÃO DO REFERIDO ENTORPECENTE, DETERMINANDO QUE O MESMO FOSSE ENCAMINHADO PARA PERÍCIA, A QUAL REVELOU SER OS ENTORPECENTES COCAÍNA, E CANNABIS SATIVA L, MOTIVANDO COM QUE A AUTORIDADE POLICIAL, RATIFICASSE A VOZ DE PRISÃO DADA ANTERIORMENTE AO CONDUZIDO, DETERMINANDO QUE O MESMO FOSSE AUTUADO EM FLAGRANTE POR TRAFICO DE ENTORPECENTE. POR MEDIDA CAUTELAR FOI REQUISITADO EXAME DE CORPO DE DELITO AO INDICIADO. LAUDO Nº 25391/2016, PERITO ELVIS MEDEIROS DE AQUINO

40º D.P. VILA STA MARIA

Endereço da delegacia : AV DEP. EMILIO CARLOS, 1251 - VILA SANTA MARIA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3936-4929



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 40º D.P. VILA STA MARIA

Folha :3

Boletim No.: 147/2016

INICIADO:19/01/2016 10:19hs e EMITIDO:19/01/2016 19:58hs

JMLNROCBDJEEFH\

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

MARCIA GOMES OLIVEIRA DE SOUZA
ESCR POL

IRAI SANTOS DE PAULA
DELEGADO DE POLÍCIA

40º D.P. VILA STA MARIA

Endereço da delegacia : AV DEP. EMILIO CARLOS, 1251 - VILA SANTA MARIA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3936-4929


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0004282-72.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MARCOS VINICIUS SOUZA ALEXANDRE**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Ana Lucia Fernandes Queiroga**

Aos 7 de março de 2017, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, no Fórum Ministro Mário Guimarães, na sala de audiências da 16ª Vara Criminal, presente a MMª Juíza de Direito, **Dra. Ana Lúcia Fernandes Queiroga**, comigo escrevente ao seu cargo abaixo assinado, instaurou-se a audiência de instrução, debates e julgamento na ação penal que a **JUSTIÇA PÚBLICA** move contra **MARCOS VINICIUS SOUZA ALEXANDRE**. Apregoadas as partes, verificou-se o comparecimento da **Dra. Cristiane Melilo Dilascio Mohmari dos Santos - Promotora de Justiça**, do acusado e da Defesa, **Dra. Ana Carolina Bezerra - Defensora Pública**. **Iniciados os trabalhos**, foram colhidos em termo apartados os depoimentos das testemunhas Fabricio Amaro De Souza e Alessandro Santos Francisco, bem como o réu foi interrogado. **Depoimentos colhidos por sistema de gravação audiovisual. Dada a palavra ao Ministério Público foi dito que:** na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, nada requereu. **Dada a palavra à Defesa foi dito que:** na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, nada

0004282-72.2016.8.26.0050 - lauda 1


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

requereu. **Em seguida, pela MMª Juíza foi dito:** Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal nada foi requerido. Assim sendo, declaro encerrada a instrução processual e passo a palavra às partes para que apresentem suas alegações. **Pelo representante do Ministério Público foi dito que:** Marcos Vinicius Souza Alexandre, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado, em razão dos fatos descritos na peça exordial, tais sejam, porque trazia consigo, transportava e guardava, para a entrega a consumo de terceiros, inúmeros “ependorfs” de cocaína e de maconha, divididos individualmente para a mercancia. A denúncia foi recebida. O réu foi citado. Foi oferecida defesa preliminar. No curso da instrução processual, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, nesta data, o réu foi interrogado. Todas as fases processuais foram rigorosamente cumpridas. É o relatório do essencial. A presente ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade restou provada pelo auto de prisão em flagrante delito; pelo auto de exibição e apreensão; pelo laudo de constatação e pelo laudo toxicológico, que atestou serem entorpecentes as substâncias apreendidas em poder do acusado (“Cannabis Sativa L” e cocaína, fls. 130 e 131). A autoria é incidente, quanto ao denunciado. Marcos Vinicius relatou que não comercializava


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

drogas, e que era apenas viciado em entorpecentes. Disse que foi solto e posteriormente foi preso no mesmo lugar, por tráfico de drogas, porque “ali era o caminho da sua casa” No entanto, a narrativa do investigado é isolada e não convence. Por outro lado, as testemunhas **policiais militares** confirmaram e ratificaram toda a narrativa da denúncia. Noticiaram que estavam em diligências, pela via pública, em local que é ponto bem conhecido de mercancia de tóxicos , e visualizaram o acusado e mais dois indivíduos desconhecidos, em atitude suspeita, sendo que o réu trazia drogas em um “estojo” , que estava nas vestes dele . Os outros acompanhantes fugiram réu , e assim que avistou a viatura policial, o investigado também tentou se evadir , sem êxito, e sequer deu tempo de dispensar as drogas. Feita a abordagem ao denunciado, os agentes públicos apreenderam os 17 pinos de cocaína e as 12 porções de maconha . Aos policiais, o acusado não admitiu que ele comercializava os tóxicos , mas o réu não aparentava estar drogado e nem se declarou usuário. Normalmente , os traficantes se dividem em grupos, um deles fica com o dinheiro e o outro fica com os entorpecentes. As versões dos Policiais Militares são uníssonas e não existe qualquer prova nos autos que infirmem suas declarações, que foram


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e compromisso de verdade. Não se apurou que os agentes públicos tivessem qualquer motivo para incriminar injustamente uma pessoa inocente. O tráfico de drogas evidenciou-se pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, e pelas circunstâncias da prisão supra descritas, bem como pela forma de acondicionamento das drogas, divididas em porções individuais, prontas para serem comercializadas ou, de qualquer forma, entregues ao consumo de terceiros. Em suma, as provas colhidas nos autos demonstram que o denunciado estava praticando ato de traficância de entorpecentes. Destarte, provada a ocorrência do crime e da autoria, de rigor a condenação deste indiciado pelo artigo 33, "caput", da Lei 11343/06. A pena base de Marcos deve ser fixada acima no mínimo legal, isto em razão de o indiciado não ser reincidente. No entanto, depreende-se a infiltração do acusado em organização criminosa, inclusive pela natureza da infração penal, violadora da saúde pública, tal seja, atividade narcotraficante e porque, ainda no curso deste processo, o acusado foi novamente preso, pela mesma conduta criminosa. O regime prisional para o início de cumprimento de pena deve ser o **fechado**, por expressa disposição legal, **sem nenhuma causa de**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

diminuição de pena , pois o tráfico de drogas não é infração penal doméstica ou caseira e o denunciado já esta enredado na comercialização espúria. Diante do exposto, com as observações aqui insertas, requer-se a procedência da presente ação penal, nos termos supra propostos, condenando-se o réu pelas imputações supra descritas. **Pela Defesa foi dito que:** MM. Juiz, o réu foi denunciado em razão da suposta prática do delito descrito no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. O nobre representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Todavia, com a devida licença, entende a Defesa que a presente ação penal deverá ser julgada improcedente, diante da absoluta insuficiência probatória, absolvendo-se o acusado com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Vejamos. **O acusado negou os fatos, dizendo que estava saindo da casa do colega, umas 5 da manhã. Neste momento passou a viatura da polícia, em que o policial que já lhe abordou antes, parou e fez nova abordagem. Disse que na abordagem anterior o policial lhe ameaçou dizendo que se o viesse no local novamente, seria preso. Disse que na oportunidade explicou que ali era o local que residia, e que sempre seria visto pela área. Ainda aduziu que não sabia que estava sendo encaminhado para delegacia por tráfico de**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

drogas, mas somente no DP soube sobre as substâncias entorpecentes. Explicou que é usuário de maconha, mas que não portava nenhuma droga naquele dia. Ademais, as provas produzidas por iniciativa da acusação, parte sobre a qual recai o ônus probatório, restringem-se aos depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências da prisão em flagrante. O policial Fabricio disse estava em patrulhamento na área conhecida como ponto de tráfico quando avistou três indivíduos, e disse que o acusado fez menção para os demais se evadir, e que ele também tentou fazê-lo, mas não conseguiu. Explicou que com o acusado foi encontrado um estojo com drogas, e quem realizou a revista foi seu parceiro. Disse que o acusado nada declarou no momento. Logo em seguida, o policial Alessandro narrou o acusado foi visto com três indivíduos, em local conhecido como ponto de drogas, e que foi abordado. Disse que foi ele quem revistou, e encontrou drogas no bolso da blusa do moletom. **E ainda respondeu que pode ter feito abordagens anteriores do acusado, mas que não tem certeza.** Ou seja, a versão do acusado não resta isolada nos autos. Saliente-se, contudo, que os depoimentos de policiais não podem, ausentes outros elementos probatórios que os corroborem, servir de fundamento para uma condenação, eis que evidentemente


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

tendenciosos, visando tão-somente a atestar para a lisura dos procedimentos que adotaram. Destarte, requer-se a **absolvição** do acusado, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento do **privilégio estampado no artigo 33, parágrafo 4º, da lei 11.343/2006**. Note-se que o acusado é primário e nada faz crer que ele tenha envolvimento com organizações criminosas. Note-se que não há qualquer certidão que comprove o trânsito em julgado de condenação em desfavor do acusado, de modo que eventuais anotações em sua "ficha criminal" não podem ser consideradas para qualquer fim, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Em caso de aplicação do privilégio, será cabível a fixação de regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o "sursis". Por certo, o crime de tráfico privilegiado não é delito equiparado a hediondo. Não se pode perder de vista o fato de que já é jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça que o homicídio qualificado privilegiado não é crime hediondo (STJ, HC 10.446/RS). Assim, não há razão para não se estender esse entendimento ao crime de tráfico. No mesmo sentido: *DJU 19.2.01, p. 242, in RBCCr 34/323, TJPR, RT 764/646, TJSP, HC 300.603-3/0, j. 12.1.00, RT 781/565*. **Com efeito, temos aqui**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

uma hipótese que em tudo se assemelha a esta, pois o crime de homicídio qualificado é hediondo, mas quando privilegiado, perde esta qualidade. Da mesma forma, o tráfico, delito equiparado a hediondo, perde esta qualidade quando praticado na forma privilegiada prevista no §4º da Lei 11.343/06. Neste sentido o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: *"O paciente foi denunciado e condenado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 à pena de sete anos e seis meses de reclusão e 750 dias multa. Apelou, mas o Tribunal a quo só reduziu a pena base ao mínimo legal, deixando de conceder a minorante prevista no art. 33, § 4º, da citada lei ao argumento de que seria facultativa sua aplicação. Insurge-se o paciente contra esse entendimento, por preencher todos os requisitos legais para sua aplicação. Observa a Min. Relatora que o delito foi cometido sob a égide da nova legislação (Lei n. 11.343/2006) e, uma vez preenchidos os requisitos previstos no seu art. 33, § 4º, é de rigor a aplicação da causa de diminuição por não se tratar de mera faculdade do julgador. Diante do exposto, a Turma, ao prosseguir o julgamento, concedeu a ordem para reformar o acórdão recorrido e a sentença condenatória, para quantificar a pena em dois anos e seis meses de reclusão e 250 dias multa e, ainda, de ofício, determinar que o*


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

paciente seja submetido ao regime aberto mediante aferição dos requisitos subjetivos e estabelecimento de condições pelo juízo das Execuções Penais.” ([HC 129.626-SP](#), **Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13/8/2009**) Assim, sob o risco de se violar o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, deve ser deferido o regime aberto de cumprimento da pena imposto à paciente. Ainda, o acusado tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que a pena a ser eventualmente aplicada é inferior ao patamar de 04 (quatro) anos previsto no artigo 44 do Código Penal. Nesse passo, urge ressaltar que se encontram presentes os demais requisitos do artigo 44, do Código Penal, porquanto: (1) o crime praticado não se deu com forma violenta ou grave ameaça à pessoa; (2) o réu não é reincidente em crime doloso e (3) os motivos e circunstâncias que se deram no delito permitem essa substituição. Cite-se, nesse passo, que, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º da lei 8072/90, **o qual sequer se aplica no caso concreto por se tratar de tráfico privilegiado**, pelo Supremo Tribunal Federal, não restam motivos para a não incidência do artigo 44 do Código Penal. Ainda, não é possível alegar que os artigos 33, § 4º e 44 da Lei 11.343/06 vedem expressamente a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

aplicação de pena restritiva de direitos e, por isso, não estariam incluídos na aludida declaração de inconstitucionalidade, uma vez que, em se tratando de crime assemelhado ao hediondo, não restam argumentos para a vedação da conversão da pena em comento. Cumpre, ademais, salientar, que, em decisão recente proferida no **HC 102678**, por unanimidade, o E. Supremo Tribunal Federal substituiu a pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em delito de tráfico de drogas, por duas restritivas de direito (Notícia do STF publicado no dia 09.03.2010), mudando assim o entendimento da E. Corte, sob a argumentação de que tal dispositivo violaria o princípio constitucional consagrado da individualização da pena. O relator foi o Min. Eros Grau. No mesmo sentido, destaca-se, ainda, o HC 97265, de relatoria do Min. Ayres Britto, em que o Pleno do E. STF decidiu que a vedação a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inconstitucional (Informativo nº 579 do STF). Confira-se o texto do mencionado Informativo: ***“Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substituição de Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos - 1 O Tribunal iniciou julgamento de habeas corpus, afetado ao Pleno pela 1ª Turma, em que condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão pela prática***


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º) questiona a constitucionalidade da vedação abstrata da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos disposta no art. 44 da citada Lei de Drogas ("Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos."). Sustenta a impetração que a proibição, no caso de tráfico de entorpecentes, da substituição pretendida ofende as garantias da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como aquelas constantes dos incisos XXXV e LIV do mesmo preceito constitucional - v. Informativo 560. O Min. Ayres Britto, relator, **concedeu parcialmente a ordem e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", constante do citado § 4º do art. 33, e da expressão "vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", contida no também aludido art. 44, ambos dispositivos da Lei 11.343/2006. HC 97256/RS, rel. Min. Ayres Britto, 18.3.2010. (HC-97256)**". Desse modo, não resta dúvida quanto à possibilidade de aplicação do artigo 44, do Código Penal, razão pela qual se requer a substituição da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, posto que preenchidos os requisitos legais. A proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao autor de tráfico privilegiado, ou seja, a quem foi beneficiado pelo disposto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, viola o princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da CF). No mais, requer-se a **fixação da pena no mínimo legal, visto que o acusado não ostenta qualquer antecedente**; e ainda, a fixação de **regime diverso do fechado para o início de cumprimento de pena**, eis que a pena cominada será bem inferior a oito anos, amoldando-se ao artigo 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal. Note-se que a pretensa hediondez da conduta em pauta não serve de óbice à fixação de regime mais brando. No mais, a vedação absoluta à fixação de regime diverso do fechado é inconstitucional, visto que afronta a individualização judicial da pena. Por fim, requer-se a possibilidade de apelar em liberdade, vez que ausentes os pressupostos da prisão cautelar. **Na sequência, pela MMª Juíza foi proferida a seguinte sentença:** **MARCOS VINICIUS SOUZA ALEXANDRE** está sendo processado pela **prática do artigo 33, "caput"**, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de janeiro de 2016, por voltas das 07:20 horas, na Avenida João dos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Santos Abreu, nº 1.600, Cachoeirinha, nesta cidade e comarca, o réu portou, transportou e trazia consigo, para entrega a consumo de terceira pessoa, ainda que gratuitamente, substâncias entorpecentes, causadoras de dependência físico e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ofertada a denúncia, foi ela recebida, após, oferecimento de defesa prévia. Na audiência foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado. Em debates, a Dra. Promotora de Justiça, pediu a condenação do réu nos termos da denúncia. Ao seu turno, a Ilustre Defensora pediu a absolvição alegando insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a aplicação de pena mínima, regime aberto para início de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade e o direito de recorrer em liberdade. **Relatei. Decido.** Trata-se de ação penal instaurada em face de **MARCOS VINICIUS SOUZA ALEXANDRE**, porque praticou o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, auto de constatação de fls. 19/20 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 129/131, no qual os peritos concluíram tratar-se de cocaína e tetrahydrocannabinol as substâncias apreendidas com o réu.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Interrogado, o réu negou a prática do crime. Disse que morava nas imediações e saiu da casa de um amigo, quando caminhava pela viela onde ocorre o tráfico de drogas e foi abordado pelos policiais, sendo conduzido para averiguação. Não viu as drogas apreendidas e não realizava o tráfico de entorpecentes no local. Acrescentou que após receber liberdade provisória neste processo foi preso novamente por acusação de tráfico de drogas. Nada obstante o acusado não ter admitido o tráfico, a autoria restou demonstrada. Com efeito, os policiais militares Fabricio Amaro de Souza e Alessandro Santos Francisco atestaram que estavam em diligências, pela via pública, em local que é ponto conhecido de mercancia de drogas, quando visualizaram o acusado e mais dois indivíduos desconhecidos, em atitude suspeita. Os outros indivíduos fugiram e o réu, assim que avistou a viatura policial, também tentou se evadir, mas acabou abordado, sendo localizado com ele o estojo onde estavam as drogas, consistentes em dezessete pinos de cocaína e doze porções de "maconha". O acusado não admitiu que comercializava os entorpecentes, mas também não aparentava estar drogado e nem se declarou usuário. Inexiste razão para recusar credibilidade aos relatos policiais, até porque, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação, hipótese inocorrente. Não se olvide que em sede de crime contra a saúde pública, a palavra dos policiais é extremamente relevante, tendo em vista, a dificuldade de encontrar nos tempos atuais, testemunhas civis dispostas a depor contra traficantes, ante o notório e justificado temor que estes impõem àqueles que, de alguma forma, possam causar-lhes embaraço. Portanto, a versão que o réu apresentou para os fatos não pode ser aceita, já que não encontra respaldo na prova dos autos. Em suma, a quantidade e variedade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada, em porções individuais, pronta para a comercialização, o modo como se comportou ao avistar a viatura, procurando se evadir, constituem circunstâncias que sustentam a conclusão, sem margem de erro, da prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte. Mesmo porque, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante. De passagem, frise-se que, para caracterização para o tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que o réu seja flagrado na prática de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que o acusado efetue uma das condutas previstas no tipo penal. Irrecusável, portanto, a condenação. Passo à dosagem da pena. Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em **05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias multa**, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde àquela data. **A menoridade não pode atenuar a pena, pois esta já foi fixada no mínimo legal.** Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar. Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a aplicar. **A quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida, inclusive cocaína, de natureza mais nociva, torna inaplicável a benesse prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, criado com objetivo de apenar minimamente aquele que se está iniciando no narcotráfico.** Não é o caso dos autos. O réu não demonstrou possuir atividade lícita, restando evidente que se dedica à traficância fazendo dela seu meio de vida, observando-se que após ser solto por este delito, logo voltou a ser preso pela prática da mesma infração, mesmo porque o tráfico não é crime artesanal e quem nele se envolve necessariamente


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

íntegra organização de pessoas para o seu cometimento. É sabido que aquele que produz a cocaína, não é o mesmo que a refina, tampouco não é aquele que a transporta e distribui para o consumo de terceiros. O mesmo se aplicando à "Cannabis sativa L". Ante o exposto, julgo **PROCEDENTE** a ação penal e **CONDENO MARCOS VINICIUS SOUZA ALEXANDRE**, qualificado nos autos a pena de **05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias multa**, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde àquela data, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no **regime fechado e deixo de conceder ao réu qualquer benefício em razão do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06 e Lei 8.072/90. O tráfico de entorpecentes é delito gravíssimo, e a sociedade ordeira e trabalhadora já não suporta viver a mercê da ação de traficantes, sendo o regime fechado àquele que responde de modo mais adequado à repressão estatal, em face da periculosidade daqueles que insistem em cometer tal delito, colocando em risco a saúde de incontável número de pessoas.** Pela mesma razão não poderá apelar em liberdade. O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Com efeito, o § 2º acrescentado


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado. Declaro a perda dos objetos apreendidos, eis que relacionados ao tráfico, oficiando-se ao setor competente para que dê destino próprio. Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, oficiando-se para tanto, se ainda não ocorreu. Desentranhe-

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

se a Folha de Antecedentes de fls. 89/100, eis que estranha a este feito, juntando-se aos autos respectivos. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e recomende-se na prisão em que se encontra. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes cientes e intimados. Registre-se e comunique-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Nada mais. Eu, __ (José Carlos Amador e Silva Matos), Escrevente, dig. e subs.

MM^a Juíza:

Ministério Público:

Defesa:

Réu:

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**